

1502794-29.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... no local conhecido como ponto de tráfico de drogas, chamado de tráfico da "Floresta". Estavam de viatura descaracterizada quando avistaram dois indivíduos se aproximando de uma pessoa desconhecida com o movimento característico de vender alguma coisa. Ao se aproximar os dois correram. Durante abordagem, um deles jogou a mochila no terreno do lado e o outro um rádio. No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502794-29.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502794-29.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS SANTANA DA CRUZ e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra MARCOS VINICIUS SANTANA DA CRUZ e MATUSALÉM DA SILVA AGUIAR TELES, tendo-os por incurso no artigo 33, "caput", da lei n.º 11.343/06, imputando-lhe os seguintes fatos: no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 11h, Rua José de Souza, Jardim Nova República, nesta cidade e comarca de Cubatão, em comunhão de esforços e desígnios de vontades, traziam consigo, para fins de tráfico, 04 tabletes Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 4.965 gramas, 04 tabletes Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 5.600 gramas, 04 tabletes Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 6.790 gramas, 02 tabletes Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 2.865 gramas, 01 tablete Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 3.210 gramas, 01 tablete Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 3.640 gramas, 34 "eppendorfs" contendo cocaína, pesando 0.5 gramas, 37 porções de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 105 gramas, 26 porções de

Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 0.25 gramas, 80 porções de cocaína, na forma de "crack", pesando 0.15 gramas, entorpecentes que causam dependência física e psíquica, conforme auto de constatação preliminar de fls. 09/11 e exame químico-toxicológico de fls. 106/110, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os corréus foram presos em flagrante e a prisão convertida em preventiva [fls. 128/129].

Notificados e citados, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 [fls. 144], os corréus, por intermédio de defensor dativo, apresentaram resposta [fls. 153/155]. A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2021 [fls. 169/170].

Designada audiência, na qual foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado interrogatório dos réus com registro em mídia digital.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal dos corréus, pugnando pela condenação nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria.

Por sua vez, em seus memoriais a Defesa dos corréus pleiteou suas absolvições por insuficiência de provas para sua condenação [art. 386 do CPP] já que os indiciados foram até o local comprar drogas, mas, em caso de entendimento contrário, requereu a desqualificação para o crime previsto no artigo 28, § 4 da lei 11343/2006. Em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência [fls. 05/08], pelo auto de apreensão e exibição [fls. 09/11], pelo laudo de exame de constatação preliminar [fls. 12/13], bem como pelo laudo definitivo de pericial (Químico-Toxicológico) [fls. 102/105 e 106/110], além da prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa e deve ser imputada aos corréus, porque comprovada pelo auto de prisão em flagrante [fls. 01/02 e 03/04] e pelos depoimentos dos policiais civis.

A tese defensiva, como se verá, está isolada nos autos

Israel Gomes dos Santos, policial civil, efetuava operação policial no local conhecido como ponto de tráfico de drogas, chamado de tráfico da "Floresta".

Estavam de viatura descaracterizada quando avistaram dois indivíduos se aproximando de uma pessoa desconhecida com o movimento característico de vender alguma coisa.

Ao se aproximar os dois correram. Durante abordagem, um deles jogou a mochila no terreno do lado e o outro um rádio. No momento em que visualizou os dois, a mochila estava no corpo de Matusalém e o rádio estava na mão do outro. Ambos jogaram os objetos em um terreno baldio. Os dois confessaram. No mesmo terreno, em uma distância de quinze metros da mochila, encontrou um saco preto com aproximadamente vinte quilos de maconha embalada de forma diferente - uma parte a granel e outra em tabletes - das drogas na mochila que estavam por unidades. Na mochila havia aproximadamente trinta quilos de cocaína, vinte de maconha e setenta a oitenta pedras de crack. Não informaram onde obtiveram as drogas. Os indivíduos só confirmaram a posse da mochila. Tinha o valor de R\$70,00 no bolso de um dos indivíduos, mas não recorda com quem estava. Não conhecia os acusados. Conta trinta anos de atividade policial e o local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Não prendeu o terceiro pois ele correu, estava mais próximo de pegar os dois réus. O rapaz que fugiu não tinha nada em mãos. Ele adotou comportamento de entregar algo para os dois acusados. No total eram quatro policiais. Não conseguiram pegar o terceiro pois dois policiais chegaram depois.

Nivaldo Heromdino Borges, policial civil, relatou ter integrado operação policial na qual os dois indivíduos foram avistados. Ao chegar no beco, visualizaram um viciado entregando e recebendo algo em troca. Ao perceber tratar-se de tráfico de entorpecentes abordaram os dois. Durante a fuga Matusalém jogou a mochila para dentro do terreno e Marcos um rádio. Chegaram policiais de apoio e, ao procurar as drogas no terreno, encontraram a mochila com drogas, o rádio e um saco contendo vinte e sete quilos de maconha, mas afirma não ter visto os corréus com essa

sacola. Não soube reconhecer quem é Matusalém e quem é o Marcos no vídeo. Não ofereceram resistência à abordagem após a fuga. Ficaram em silêncio. Os dois estavam juntos. O local é uma biqueira chamada de "Floresta" e já realizou diversas abordagens por tráfico de drogas. Não conhecia os corréus antes dos fatos. Não recorda a cor da mochila ou a quantidade de drogas. Esclareceu ter o local diversos becos e, por isso, não conseguiu localizar o terceiro. Ao todo havia seis policiais.

Interrogado em juízo, o réu Marcos negou os fatos. Afirmou ser usuário de drogas e ter ido até o local para comprar, quando apareceram os policiais civis descaracterizados. Deitou no chão e o rapaz que estava efetuando a venda correu para o beco dispensando a mochila e o rádio. Chegou outra viatura, reviraram o local e encontraram mais drogas. Não conhecia Matusalém antes da prisão. Não deu tempo de comprar o entorpecente. Pagaria o entorpecente com a quantia de cinco reais em seu bolso. Negou trazer consigo rádio comunicador. O rapaz que estava vendendo estava com a mochila nas costas, quando foi dada voz de prisão, deitou no chão, não sabe dizer se o indivíduo dispensou a mochila ou se os policiais apareceram com outra. Nega os policiais terem alguma razão para incriminá-lo injustamente ou conhecê-los. Afirma ser o local conhecido como ponto de tráfico, "Bolsão oito". Não conhece o local como "Boca da floresta". Antes da prisão trabalhava como soldador. Estava no local para comprar droga para consumo. No total eram oito policiais. Não sabe se Matusalém teria alguma razão para incriminá-lo, pois não o conhece.

Interrogado em juízo, o réu Matusalém da Silva Aguiar Teles negou os fatos. Quando foi preso pela polícia trazia consigo seu celular em mãos. Não sabe o que Marcos tinha em mãos, pois tinha acabado de sair da casa de sua mãe. O local é conhecido como ponto de tráfico. Foi até lá comprar maconha. O local também é conhecido como "Biqueira da floresta". Tinha consigo a quantia de dez reais. Conheceu Marcos na prisão. No local havia mais um rapaz, o vendedor, era alto, com cerca de 1,80m e pardo, portando um rádio comunicador na mão e uma mochila nas costas. Disse ser a forma que "eles ficam" para serem identificados. Negou ser dono da mochila preta. Não viu Marcos com rádio nas mãos. Conhecia um dos policiais civis, mas não sabe o nome. Em uma situação que não aceitou a abordagem foi liberado e dito que "mais pra frente iriam me pegar". Não tem nenhuma desavença com os policiais civis ouvidos em audiência ou com o corréu Marcos. É usuário de drogas há cinco anos.

Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

Interrogados em juízo, os corréus negaram a veracidade da imputação.

A negativa inconsistente não infirma a versão das demais testemunhas, tornando imperiosa a responsabilidade criminal dos corréus, anotando-se que os policiais civis corroboraram em juízo a dinâmica dos fatos constante da denúncia, no sentido de que os corréus foram abordados após conduta suspeita [movimento de entregar e receber algo em troca] no "tráfico da floresta", local conhecido como ponto de tráfico de drogas, trazendo consigo rádio comunicador, mochila com entorpecentes e ao serem abordados empregaram fuga e arremessaram os bens em terreno próximo.

Os policiais acrescentaram que, no local, os corréus admitiram a propriedade das drogas.

Em interrogatório na fase policial, os corréus permaneceram em silêncio [fls.17/18 e 19/20] e, em juízo, confessaram a posse dos entorpecentes para consumo próprio. Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo

Penal. Aliás, os atos funcionais do servidor público são presumidos verdadeiros [CF, art. 37].

Assim, não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, “[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” [STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996]. Por oportuno, confira-se: “Urge destacar que nada impede que policiais como quais quer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública”. [TJSP, Ap. n. 0000604-19.2016.8.26.0545, rel. Des. Herman Herschander, j. 07.12.2017].

A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade própria e prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.

No mais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal [CPP, art. 155].

Outrossim, a legislação processual penal em vigor não obriga a participação de testemunhas civis no momento em que ocorre a prisão em flagrante, mostrando-se, pois, legítimo o procedimento dos agentes de segurança pública. Aliás, notória é a dificuldade de encontrar pessoas que, tendo presenciado o estado de flagrância, estejam dispostas a testemunhar contra narcotraficantes.

Induvidosa a apreensão, em poder dos corréus, da droga descrita na denúncia.

No mais, a negativa dos corréus está isolada nos autos, não tendo carreado aos autos qualquer indício de suas alegações de estarem comprando drogas para consumo próprio. Nesse sentido, já se decidiu que “de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado.” [STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 4.376/SP, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.1.2005].

Assim sendo, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do crime: [a] a quantidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes; [b] o dinheiro apreendido; [d] apreensão de rádio transmissor [e] local conhecido ponto de tráfico na Comarca; [f] a narrativa dos policiais civis.

A quantidade de entorpecentes apreendida e a posse de rádio comunicador [fls.09/11] constatados através de laudo pericial [fls.102/105 e 106/110] ratificam a versão policial.

Inviável, pois, acolher-se a pretensão absolutória ou desclassificatória, ressaltando-se, ainda, que eventual condição de usuário não exclui a de traficante.

Assim, pois, é de se reconhecer que os corréus traziam consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os entorpecentes apreendidos, conduta que se amolda à figura típica prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006.

A conduta de tráfico imputável aos réus - Matusalém era quem trazia consigo uma mochila nas costas e Marcos um rádio HT nas mãos - deve ficar restrita à quantidade existente na mochila, a saber, conforme depoimento policial [fls. 14/15], “34 pinos de COCAÍNA, 37 tiras de MACONHA embaladas individualmente em plástico transparente, 26 pequenas porções de MACONHA embaladas individualmente em plástico transparente, 80 pedras de CRACK embaladas individualmente em plástico transparente, além de R\$78,60 em dinheiro cédulas e moedas”.

Os demais entorpecentes apreendidos na ocasião não podem ser imputados, com segurança, aos réus, favorecidos pela dúvida [porções de maconha, cerca de 20

quilos, distribuídos em 14 tabletes e aproximadamente 07 quilos de maconha a granel].

Assim sendo, o fato é típico e antijurídico, sendo certo que a significância da lesão ao bem jurídico tutelado impõe a incidência da norma penal, não estando os acusados amparados por qualquer causa de exclusão da ilicitude ou que afaste sua culpabilidade.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, notadamente aquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Possível a dosimetria conjunta, por economia processual. A propósito, confira-se: “O princípio da individualização da pena não exige que o Magistrado, diante de réus que ostentam as mesmas circunstâncias judiciais - como no caso concreto -, realize um procedimento de dosimetria da reprimenda em separado para cada um deles, podendo, desde que o faça de forma fundamentada, agrupá-los nas razões que lhes forem comuns e justifiquem a aplicação da reprimenda naquele quantum” [AgRg no Ag 1130380, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.03.2017]. Ainda: AgRg no HC 208.626/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.09.2014. A natureza variada e a quantidade relevante da substância entorpecente impõem maior reprimenda.

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo. Apenas o corréu Marcos apresenta maus antecedentes, porque multirreincidente, contando duas condenações com trânsito em julgado, uma das quais será utilizada para agravamento de sua pena-base [0000094-04.2014.8.26.0536 - fls. 138/140], enquanto a outra como circunstância agravante genérica da reincidência, ressaltando-se que esse procedimento não configura bis in idem [cf. STJ - HC n. 180658, rel. Min. Laurita Vaz e STJ - HC 167.459, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze]. A conduta social e personalidade [“deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu” [Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588], à míngua de elementos de provas objetivas desabonadores, são favoráveis aos réus. O motivo do crime integra sua definição típica, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias e consequências do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o impulso delitivo do agente, fato, todavia, que não agrava a pena por se tratar de circunstância neutra [cf. STJ - HC n. 217.819, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura].

Pena-base com acréscimo de um sexto para Matusalém.

Pena-base com acréscimo de um quinto para Marcos.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a sopesar relativamente ao corréu Matusalém.

Por seu turno, quanto ao corréu Marcos, em segunda fase, verifica-se presente a circunstância agravante da reincidência específica, prevista no art. 61, I, do Código Penal [processo n. 0001258-33.2016.8.26.0536, fls. 138/140], inexistindo circunstância atenuante a ser valorada. Assim, a pena intermediária deve ser fixada, com o acréscimo de um quinto.

Registre-se que a confissão espontânea de que é usuário de drogas não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, aos acusados pelo tráfico de drogas” [HC n. 373.613, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.12.2016].

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Por outro lado, há causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

O legislador, ao prever a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, almejou conferir tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, reduzindo a reprovabilidade de sua conduta prejudicial à saúde pública.

Para a incidência da causa minorante é de rigor a concorrência dos requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração de organização criminosa.

Quanto ao corréu Marcos, por si, a reincidência, mormente específica, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Por sua vez, relativamente ao corréu Matusalém, a conduta de dedicar-se a atividades criminosas pode ser inferida das circunstâncias objetivas que permeiam o crime e subjetivas quanto à pessoa do agente, que tornem evidente, acima da dúvida razoável, a incursão do traficante não reincidente e que não ostente maus antecedentes na atividade criminosa com habitualidade.

Assim sendo, a dedicação às atividades criminosas pode decorrer da conduta social desajustada do réu, concurso eventual de pessoas, receptação, petrechos relacionados ao tráfico e exame da quantidade, variedade e nocividade da droga. Com efeito, "A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." [SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129].

Nenhuma atividade lícita foi comprovada nos autos.

Em especial no caso, o ponto de tráfico de drogas, uso de rádio comunicador, concurso de pessoas, a quantidade significativa, a variedade e a nocividade da droga, por demonstrar destacável potencial de lesividade à saúde pública, autorizam conclusão de que o agente se dedica às atividades criminosas.

Pena definitiva de: [a] 5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias-multa para o corréu Matusalém; [b] 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, com 720 dias-multa, para o corréu Marcos.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49; Lei n. 11.343/06, art. 43], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF - HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli]. Segundo Leciona Cezar Roberto Bitencourt, "quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado (necessário e suficiente) para aquele caso concreto e para aquele apenado (art. 33, § 3º, do CP)" [Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 450].

Ademais, os dados fáticos da conduta delitiva, quando demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena [cf. HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012].

Imperiosa a fixação do regime inicial fechado na hipótese e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade relevante, diversidade e a natureza das drogas apreendidas [Lei n. 11.343/2006, art. 42]. Não se pode ainda desprezar a dedicação à atividade criminosa revelada pelo histórico delitivo do corréu Marcos especialmente, tendo sido ambos presos em flagrante em local conhecido ponto de tráfico na Comarca. Nesse contexto, é necessária resposta penal mais efetiva, como forma de retribuição proporcional à gravidade da conduta, pois, a considerar a natureza e a variedade

das drogas apreendidas, o regime inicial mais brando e eventual substituição da reprimenda corporal por penas alternativas não se revelam suficientes para a reprovação e a prevenção do delito em comento.

A detração penal [desconto do tempo de prisão provisória] para fins de abrandamento do regime prisional inicial [CPP, art. 387, §2º] é descabida na hipótese, por ausência do requisito objetivo.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [CP, art. 44, I e III] e a suspensão condicional da pena [CP, art. 77, caput e II], especialmente à vista da vedação prevista no do art. 44, caput, da Lei 11.343/06 [cf. REsp n. 1358147, rel. Min. Marilza Maynard, j. 18.4.2013].

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO:

[a] MARCOS VINICIUS SANTANA DA CRUZ, qualificado anteriormente, às penas de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, com 720 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

[b] MATUSALÉM DA SILVA AGUIAR TELES, qualificado anteriormente, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, com 583 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Dê-se à droga apreendida a destinação prevista no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, preservada quantidade para eventual contraprova.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus comissi delicti [existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do Código de Processo Penal] pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a dinâmica desenvolvida para o exercício da traficância, é de ser mantida prisão cautelar, mormente considerando que os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual, para, ao final, serem condenados à prática de crime equiparado a hediondo, cujo cumprimento se iniciará no regime fechado e estavam traficando, de modo organizado droga altamente viciante [cocaína e crack], cujos efeitos deletérios são por todos conhecidos, tudo a revelar que a liberdade dos réus colocará em risco a ordem pública [CPP, art. 312], revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa [CPP, art. 282, §6º]. Por fim, observo que, diante da prova no sentido de que os réus estavam realizando a mercancia da droga, resta indiscutível que os bens apreendidos eram utilizados para a prática do tráfico ou dela decorreram. Nessa situação, imperioso o perdimento.

Inaplicável à hipótese a fixação do valor mínimo para reparação de danos [CPP, art. 387, IV] por se tratar de crime vago.

Após o trânsito em julgado: [a] expeçam-se guias de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; [b] notifiquem-se os condenados para pagamento da pena de multa, no prazo de dez dias, nos termos do art. 50, caput, do Código Penal [TJSP, Provimento CG n. 11/2015]; [c] oficie-se o TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF; [d] oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Fixo os honorários advocatícios das patronas dos réus, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso e expedindo-se as competentes certidões.

Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim e se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P. I. C.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA